

刑法
No125

H28-13

(配点：4)

月 日

月 日

次のアからオまでの各記述における甲の罪責について、判例の立場に従って検討し、() 内の犯罪が既遂になる場合には1を、未遂にとどまる場合には2を、既遂にも未遂にもならない場合には3を選びなさい。

ア. 甲は、所持金がなかったことから代金を支払わずに食事をしようと考え、飲食店に行って料理を注文し、これを食べた後、代金を請求した店員に対し、財布を忘れたので自宅に取りに帰ると嘘を言ったが、店員にその嘘を見破られた。(詐欺罪)

イ. 甲は、Aを殺害しようと考え、Bから致死性の毒薬であると告げられて小瓶入りの液体を購入し、コーヒーに同液体を入れて、これをAに飲ませたものの、同液体は水であったため、Aは死亡しなかった。(殺人罪)

ウ. 甲は、Aと同居している自宅を燃やそうと考え、自宅の和室に新聞紙が入った段ボール箱を置き、同新聞紙にライターで点火したが、その直後に帰宅したAが燃えている同段ボール箱を発見して消火したため、同段ボール箱の直下の畳だけが焼損した。(現住建造物等放火罪)

エ. 甲は、駅のホームのベンチで寝ているAの隣に座ったところ、Aのズボンのポケットに財布が入っていることに気付き、これを盗もうと考え、手を差し伸べて同ポケットの外側に触れたが、駅員が近付いてきたので、財布に触れることはできなかった。(窃盗罪)

オ. 甲は、交通事故を装って保険会社から保険金をだまし取ろうと考え、Aに依頼して、甲運転の自動車にA運転の自動車を衝突させ、警察官に交通事故を申告したが、Aが警察官から追及されて偽装事故であると認めたため、保険金を請求しなかった。(詐欺罪)

№125	既遂と未遂の区別						正答率
H28-13	正解	ア 1	イ 3	ウ 2	エ 2	オ 3	39%

ア 既遂になる

最決昭 30.7.7 (百選Ⅱ53事件)。詐欺罪 (246 条) は、相手方が財物又は財産上の利益を交付し、それによって財物の占有又は財産上の利益が行為者の側に移転したときに既遂となる。本記述において、甲は、代金を支払う意思がないのに飲食店で料理を注文し、これを食べているから、料理を食べた時点で詐欺罪 (246 条 1 項) は既遂となる。判例も、所持金がなく、かつ、代金支払の意思がないのにあるかのように装って、飲食、宿泊をなした後、自動車で帰宅する知人を見送ると欺いて被害者方の店先に出でたまま逃走したという事案において、「宿泊、飲食等をしたときに刑法 246 条の詐欺罪が既遂に達した」としている。したがって、本記述の甲は、詐欺罪の既遂になる。

イ 既遂にも未遂にもならない

大判大 6.9.10。判例は、殺意を持って硫黄粉末を被害者に服用させた事案において、方法が殺害の目的を達するに付き絶対不能として、殺人未遂罪の成立を否定している。このような判例の立場に照らせば、本記述において甲が A に飲ませた液体は水であり、A の死亡結果を引き起こすことは絶対不能であるといえる。そのため、甲の行為は不能犯とされ、殺人未遂罪は成立しない。したがって、本記述の甲は、殺人罪の既遂にも未遂にもならない。

ウ 未遂にとどまる

最判昭 25.12.14。本記述では、家屋の従物である畳の焼損が「建造物」たる家屋の一部の焼損として、現住建造物等放火既遂罪 (108 条) を構成するかが問題となる。同罪にいう「建造物」とは、家屋その他これに類似する建築物をいい、屋根があり、壁又は柱で支持されて土地に定着し、少なくともその内部に人が出入りすることができるものをいう。そして、判例によれば、毀損せずに取り外すことのできる建具や畳は「建造物」の一部ではない。本記述の甲は、媒介物たる新聞紙に点火をしているから、同罪の実行の着手は認められるが、畳のみを焼損させたのであるから「建造物」を焼損したとはいえず、現住建造物等放火既遂罪は成立しない。したがって、本記述の甲は、現住建造物等放火罪の未遂にとどまる。

エ 未遂にとどまる

最決昭 29.5.6。判例は、本記述と類似の事案において、「被害者のズボン右ポケットから現金をすり取ろうとして同ポケットに手を差ししのべその外側に触れた以上窃盗の実行に着手したものと解すべき」とであるとして、窃盗罪 (235 条) の実行の着手を肯定している。したがって、本記述の甲は、窃盗罪の未遂にとどまる。

オ 既遂にも未遂にもならない

大判昭 7.6.15。本記述では、保険金騙取目的で交通事故を装って自動車同士を故意に衝突させた場合において、警察官に交通事故を申告した時点で詐欺罪の実行の着手が認められるかが問題となる。判例は、保険金騙取目的で家屋に放火したが、保険会社に対し保険金の請求をしなかったという事案において、保険会社に支払の請求をしていない以上、詐欺罪の実行の着手は認められないとしている。本記述の甲は、交通事故を偽装して警察官に事故の申告をしたにすぎず、警察官からの追及を受けて保険会社に対する保険金の請求を断念しているため、詐欺罪の実行の着手は認められない。したがって、本記述の甲は、詐欺罪の既遂にも未遂にもならない。